

<제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제6절 증명책임>

I. 서설 - 증명책임의 의의

1. 개념

- 증명책임이란 요건사실의 존부가 확정되지 않은 상태, 즉 진위불명의 상태로 인하여 판결에서 불이익을 입게 되는 당사자의 법률적 지위를 의미한다. 법관은 심리 결과 사실관계가 명확히 밝혀지지 않았더라도 재판을 거부할 수 없으므로, 증명책임의 원칙에 따라 그 사실이 존재하지 않는 것으로 취급하여 패소의 위험을 특정 당사자에게 부담시킨다. 이를 객관적 증명책임이라 하며, 소송 중 당사자가 패소의 위험을 피하기 위해 증거를 제출해야 하는 활동상의 의무인 주관적 증명책임과 구별된다.

2. 구별

(1) 거증책임

- 주관적 증명책임 혹은 거증책임은 소송의 진행 과정에서 당사자가 자기에게 유리한 심증을 형성하기 위해 증거를 제출하는 행위적 부담을 말한다. 이는 소송 도중 심증의 변화에 따라 당사자 간에 이동할 수 있다는 점에서 객관적 증명책임과 차이가 있다.

(2) 본증과 반증

- 본증은 증명책임을 지는 당사자가 그 사실의 확신을 주기 위해 제출하는 증거이며, 반증은 상대방이 그 확신을 흔들어 다시 진위불명의 상태로 되돌리기 위해 제출하는 증거를 의미한다. 반증은 진위불명 상태만 만들어도 목적을 달성하므로 본증과 같은 정도의 확신을 요구하지 않는다.

II. 증명책임의 분배

1. 증명책임의 분배의 의의

- 증명책임의 분배란 어떤 사실이 진위불명일 때 누가 패소의 불이익을 입을 것인가를 미리 정하는 기준을 말한다. 이는 재판의 예견가능성을 확보하고 법적 형평성을 유지하기 위해 매우 중요하다.

2. 법률요건분류설의 내용과 비판

(1) 내용

- 각 당사자는 자기에게 유리한 법률효과를 발생시키는 법률규정의 요건사실에 대하여 증명책임을 진다는 학설이다. 통설과 판례의 입장이다. 권리 발생사실은 권리 주장자가, 권리장해 · 권리소멸 · 권리저지사실은 그 상대방이 증명책임을 부담한다.

(2) 비판

- 법문의 규정 방식에 따라 증명책임이 결정되므로 입법자의 입법 기술에 지나치게 의존한다는 비판이 있다. 또한, 구체적 사안에서 증거의 거리나 증명의 곤란성 등을 고려하지 못하여 실질적 형평에 어긋날 수 있다는 지적이 존재한다.

3. 증명책임의 분배에 대한 신설의 내용과 비판

(1) 내용

- 법률요건분류설의 형식성을 극복하기 위해 등장한 견해들로, 증거거리설, 위험영역설, 증명곤란설 등이 있다. 증거에 접근하기 쉬운 자나 위험을 통제할 수 있는 영역 내에 있는 자가 증명책임을 져야 한다는 실질적 공평을 강조한다.

(2) 비판

- 기준이 다의적이고 모호하여 법관의 자의가 개입될 우려가 크며, 소송 전 단계에서 당사자가 누가 패소할지 예측하기 어렵게 만든다는 법적 안정성 측면의 비판을 받는다.

III. 증명책임의 전환

1. 증명책임의 전환의 의의

- 증명책임의 전환이란 원칙적인 분배 기준에 따르면 일방이 증명해야 할 사실을, 특정한 사정으로 인해 타방이 그 반대 사실을 증명하도록 책임을 바꾸는 것을 말한다. 이는 대등한 당사자 간의 실질적 무기대등을 보완하기 위한 장치이다.

2. 증명책임의 전환의 유형

(1) 법률에 의한 전환

- 법률이 명문으로 증명책임을 전환하는 경우이다. 민법 제759조(동물의 점유자의 책임) 등에서 점유자가 상당한 주의를 하였음을 증명하지 못하면 책임을 면할 수 없도록 규정한 것이 예이다.

(2) 판례에 의한 전환

- 제조물책임이나 의료소송, 환경오염 소송 등 증거의 편재가 심한 현대형 소송에서 판례는 해석을 통해 증명책임을 완화하거나 전환한다. 가해자 측에서 자기의 과실 없음을 증명하도록 유도하는 방식으로 운용된다.

IV. 증명책임의 완화

1. 증명책임의 완화의 의의

- 증명책임의 분배 자체를 바꾸지는 않되, 증명의 정도를 낮추어 주거나 간접사실을 통해 주요사실을 추단하게 함으로써 증명책임자의 부담을 덜어주는 기법이다.

2. 법률상 추정

- 법률에 규정된 전제사실이 증명되면 요건사실이 존재하는 것으로 법률이 인정하는 것이다. 이를 깨뜨리기 위해서는 상대방이 반대 사실을 증명해야 하므로 증명책임의 전환과 유사한 효과를 낸다.

3. 일응의 추정

- 표표적 증명이라고도 하며, 경험칙을 이용하여 특정 간접사실이 증명되면 그에 따른 주요사실을 추정하는 기법이다. 예를 들어 자동차가 보도를 침범하여 행인을 쳤다면 운전자의 과실이 일단 추정된다. 상대방은 경험칙의 적용을 배제할 만한 특수한 사정을 제시하여 이를 번복할 수 있다.

4. 간접반증

- 증명책임이 없는 상대방이 주요사실과 양립할 수 없는 별개의 간접사실을 증명함으로써, 본증에 의한 추인을 방해하는 방법이다. 이는 현대형 소송에서 원고의 증명 부담을 덜어주기 위해 피고 측에 반대 사실의 증명을 요구하는 형태로 자주 활용된다.

V. 주장책임

1. 주장책임의 의의

- 당사자가 자기에게 유리한 법률효과를 발생시키는 요건사실을 변론에서 주장하지 않으면, 그 사실이 없는 것으로 취급되어 법원이 판결의 기초로 삼을 수 없는 불이익을 말한다. 이는 변론주의 원칙의 당연한 결과이다.

2. 주장책임의 적용범위

- 주장책임은 원칙적으로 주요사실에 대해서만 적용된다. 간접사실이나 보조사실은 당사자의 명시적 주장이 없더라도 법원이 증거조사를 통해 인정할 수 있다. 다만, 취소권이나 해제권과 같은 형성권의 행사는 그 권리 행사의 의사표시가 있었다는 사실이 반드시 주장되어야 한다.

3. 주장책임의 분배

- 주장책임의 분배는 증명책임의 분배와 일치한다. 즉, 특정 사실에 대해 증명책임을 지는 당사자가 그 사실에 대한 주장책임도 함께 부담하는 것이 원칙이다. 이를 주장책임과 증명책임의 일치 원칙이라 한다.

VI. 결론

- 증명책임은 현대 민사소송법에서 사법의 척도라 불릴 만큼 중추적인 역할을 수행한다. 진위불명의 상태에서 법관의 자의적 판단을 방지하고 당사자에게 공평한 패소 위험을 분배함으로써 재판의 객관성을 담보한다. 과거 법률요건분류설에 치중했던 엄격한 분배 원칙은 오늘날 현대형 소송의 등장과 함께 증명책임의 전환 및 완화라는 유연한 해석론을 통해 보완되고 있다. 특히 의료, 환경, 정보통신 등 전문적 영역에서 일반 당사자의 증명 곤란을 해소하기 위한 판례의 노력은 실질적 형평성을 구현하는 핵심적 수단이 된다. 다만, 이러한 완화가 법적 안정성을 해치지 않도록 논리적 근거와 한계를 명확히 설정해야 한다. 결국 증명책임론은 절차적 정의와 실체적 진실 발견이라는 두 가지 가치를 조화롭게 유지하며, 법치주의 하에서의 공정한 재판을 실현하는 최후의 보루로서 기능한다.